

1501409-43.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: KLEBER LELES DE SOUZA

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... sabia que no local era praticado o tráfico de drogas, mas não conhecia Alexsandra, e não sabia nada acerca de eventual participação anterior dela no tráfico de drogas.

A testemunha Willian Divetta Carrieri, policial civil, ouvido em juízo, confirmou o depoimento de Adriano. Confirmou que o local é conhecido ponto de venda de drogas. Disse que parou na entrada da viela, e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501409-43.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501409-43.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2191650/2021 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Silva Bezerra e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). KLEBER LELES DE SOUZA

Vistos,

LUCAS SILVA BEZERRA e ALEXSANDRA DA CONCEIÇÃO GUERREIRO, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, atuando previamente ajustados, unidos em desígnios e com divisão de tarefas para o fim comum, traziam com eles e guardavam, para fins de entrega a consumo de terceiros, 2 embalagens plásticas contendo 1,67g da droga cocaína, 11 embalagens plásticas contendo 3,51g da mesma droga, na forma de crack e 13 embalagens plásticas contendo 43,94g da droga maconha, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. laudo de constatação provisória de fls. 41/43.

Segundo o apurado, os denunciados uniram esforços para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo que na divisão de tarefas para o fim comum, cabendo ao acusado a distribuição de drogas e o recebimento dos valores dos usuários, enquanto a acusada realizaria os atendimentos inicial dos usuários, direcionando-os até o comparsa, bem como controlando a presença de policiais ou viatura. Assim, na data dos fatos, policiais civis realizavam diligências em conhecido ponto de venda de drogas, valendo-se de viatura descaracterizada, quando visualizaram a acusada na

entrada da viela e o acusado parado no meio da mesma viela e em poder de uma sacola, ocasião em que passaram a monitorá-los. Durante a breve campana, os policiais visualizaram a acusada sendo abordada por indivíduos e, após breve conversa, os orientava a rumar até o acusado, com quem trocavam objetos. Diante da prática de atos compatíveis com a traficância, os investigadores abordaram os denunciados, sendo que o acusado foi surpreendido em poder de R\$ 15,00 e guardando no interior da sacola 2 porções da droga cocaína, 11 porções de crack e outras 13 porções de maconha.

O réu Lucas foi regularmente notificado (fls. 156), tendo apresentado defesa preliminar as fls. 55/58. A denúncia foi recebida a fls. 172. A ré Alexsandra foi regularmente notificada (fls. 159), tendo apresentado defesa preliminar as fls. 55/58. A denúncia foi recebida a fls. 172 e a ré foi regularmente citado (fls. 213).

Ressalto que Lucas não foi localizado para ser intimado da audiência, sendo aplicados, em relação a ele, os efeitos da revelia.

Na audiência de instrução debates e julgamento foi colhida a prova oral.

Ao final, as partes se manifestaram em debates orais, o que foi registrado pelo sistema de gravação de áudio e vídeo, nos termos do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não havendo preliminares a serem apreciadas, pelo mérito a presente ação penal é PROCEDENTE em relação a LUCAS e IMPROCEDENTE em relação a ALEXSANDRA.

A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo pericial de fls. 41/43, que atestou positivo para as substâncias entorpecentes tetrahidrocannabinol (THC - maconha) e cocaína, substâncias estas consideradas ilícitas pela Portaria 344/98 SVS/MS. Consigno que a perícia não foi contestada pela defesa.

No que se refere à autoria, entendo que esta somente restou evidenciada em relação a LUCAS, havendo dúvida intransponível em relação a ALEXSANDRA.

É certo que de acordo com o art. 155, do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, estes elementos informativos da investigação foram corroborados pela prova produzida em contraditório, mas apenas em relação ao acusado LUCAS.

Em juízo, a testemunha Adriano Moreira Ponte, policial civil, afirmou que o local é conhecido como "Fazendinha", sendo ponto conhecido de tráfico de drogas. Em viatura descaracterizada, os policiais pararam de frente a uma escadaria, e visualizaram uma mulhe parada na entrada da escada, e um indivíduo parado no meio da escadaria. Em dado momento, uma pessoa se aproximou, e a mulher indicou o rapaz que estava no meio da escadaria. O indivíduo foi até ele, e depois retornou. Depois desta dinâmica, os policiais decidiram pela abordagem. O depoente abordou a mulher, e seu parceiro subiu a escadaria. Disse que a mulher inicialmente negou estar traficando, mas depois admitiu que estava ali orientando os usuários, indicando a pessoa de Lucas. Disse que Lucas estava com a sacola nas mãos, no interior da qual estavam as drogas. Questionado, disse que já sabia que no local era praticado o tráfico de drogas, mas não conhecia Alexsandra, e não sabia nada acerca de eventual participação anterior dela no tráfico de drogas.

A testemunha Willian Divetta Carrieri, policial civil, ouvido em juízo, confirmou o depoimento de Adriano. Confirmou que o local é conhecido ponto de venda de drogas. Disse que parou na entrada da viela, e visualizou Alexsandra coordenando o acesso à viela, e indicando a pessoa de Lucas, que estava no meio da viela. Alexsandra não percebeu a presença dos policiais, e eles então decidiram pela abordagem. Disse que seu parceiro abordou Alexsandra, e ele abordou o indivíduo, na posse de quem estavam as drogas. A viatura era descaracterizada. Disse que Lucas assumiu a traficância, e indicou Alexsandra como a pessoa que estava controlando o acesso dos usuários. Em juízo, referida testemunha reconheceu o acusado Lucas, por Observe-se que os depoimentos prestados em juízo por estes policiais, além de plenamente coerentes, estão em perfeita harmonia àqueles por eles prestados perante a autoridade policial. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tais depoimentos. Não há nos autos prova alguma, sequer

indícios, de que os policiais tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente o réu. E, afinal, o fato de estas testemunhas serem policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer a prova coligida, sobretudo porque seus depoimentos estão amparados em outros elementos de convicção.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser "inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372). E ainda: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC n.º 74.608-SP - STF).

Deve-se ressaltar que o acusado Lucas da Silva Bezerra, em seu interrogatório prestado perante a autoridade policial, alegou que era a terceira vez nessa semana que trabalhava para o tráfico, na função de "vapor" (pessoa responsável pela venda da droga), que recebia 10% do valor arrecadado na venda da droga durante o seu turno, em média de R\$ 130,00 por dia. Declarou que ficaria naquele local das 8:00 às 20:00 horas, que chega no local no horário combinado e recebe a sobra da droga do indivíduo que estava no período noturno e que durante o dia outro indivíduo (desconhecido), passa e abastece o mesmo com mais drogas. Declarou que o abastecedor ainda não havia passado, por isso tem pouca droga com ele. Declarou que nos últimos dias em que trabalhou na biqueira, chamou Alexsandra da Conceição Guerreiro, a acusada, que reside próximo ao local, para ajudá-lo, ficando no começo da viela olhando se alguma viatura policial se aproximava do local (olheira) e que no final do dia pagava a mesma com parte do valor recebido. Declarou que está desempregado há mais de 3 anos, que se mantém com o dinheiro da venda das drogas. Declarou que nesta data foi abordado por policiais e trazido até esta delegacia. Em juízo, o acusado não foi interrogado, eis que se tornou revel.

A acusada Alexsandra da Conceição Guerreiro, em sede policial, alegou que que reside na mesma rua em que foi capturada, não sabendo indicar o número e que faz uso da internet da casa de uma colega que reside no início da viela, razão pela qual foi encontrada naquele local. Declarou que durante o período em que estava naquele local, usuários de drogas chegavam e perguntavam "onde está a loja?" se referindo a "biqueira", então a mesma, por educação, indicava o local exato e a pessoa que estava vendendo as drogas nesta data. Declarou que não trabalha para o tráfico de drogas como "capa" (olheira), que estava no local apenas para usar internet, já que não tem em casa e a do seu telefone havia acabado. Declarou que policiais a viram indicando a "biqueira" para as pessoas que a procuravam, então entenderam que ela estava trabalhando no local, mas não estava, ainda assim disseram que estava presa e foi trazida até esta delegacia. Questionada sobre filhos, declarou possuir uma filha de 7 anos, que reside com o irmão Mike.

Em juízo, Alexsandra voltou a negar o dolo, aduzindo que estava parada na frente do escadão porque morava nas proximidades. Disse que Lucas chegou a chamá-la para "trabalhar" no tráfico no dia dos fatos, mas ela não aceitou. Afirmou que estava usando celular e aproveitando-se do sinal de wi-fi de uma vizinha. Disse, todavia, que como residia nas proximidades do local em que eram vendidas as drogas, eventualmente pessoas vinham até ela e ela apenas indicava onde seria a biqueira sem, contudo, participar efetivamente no tráfico.

Ora, o relato de Alexsandra não contraria o depoimento dos policiais, pois eles confirmaram que, de fato, a viram indicar o local onde seriam vendidas tais substâncias. Tal fato, contudo, não obstante seja conduta externa bastante significativa, gerando indícios de que estivesse traficando, não é suficiente para comprovar o dolo e a participação dela no tráfico, eis que havia necessidade de comprovação do liame subjetivo (uma vez que, com ela, nada de ilícito foi encontrado). Pondero que, no caso em tela, este liame derivaria, basicamente, do

interrogatório de Lucas em sede policial, que, contudo, não foi confirmado em Juízo, eis que ele não foi localizado para confirmá-lo. Ressalto que Alexsandra, de fato, declarou residir no local, não havendo provas em sentido contrário. Neste contexto, não é inverossímil a alegação de que soubesse onde as drogas eram vendidas, indicando-o a eventuais usuários o local. Embora possa ser considerada conduta moralmente reprovável, não há crime diante da ausência de prova efetiva do dolo de traficar. Por esta razão, também entendo não ser o caso de desclassificação da conduta para aquela do art. 37, da Lei de Drogas.

Ressalto, ademais, que condutas posteriores imputadas à ré não justificam, por si só, a condenação por fato anterior.

Com relação a Lucas, é certo que os policiais confirmaram que ele estava efetivamente praticando a traficância, mantendo as drogas na sua posse. Neste contexto, se mostra segura a prova de autoria e materialidade em seu desfavor, notadamente porque não foram afastadas pelas demais provas produzidas.

Ora, o local em que ocorreu a prisão (conhecido ponto de tráfico de drogas), a forma como estava embalada a droga, a quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, o encontro de dinheiro e a observação prévia feita pelos policiais são indicativos do intuito de traficância. Por outro lado, pela própria quantidade e demais circunstâncias, não há como desclassificar a conduta para o porte de entorpecente para consumo pessoal, sendo certo que a figura do usuário não é incompatível com a do traficante, podendo coexistirem pacificamente em uma única pessoa.

Não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu LUCAS se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, notadamente porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. - HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Comprovada, assim, a autoria e a materialidade do delito em relação a LUCAS. Impõe-se, nestes termos, a condenação do acusado.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, seguindo os critérios do art. 42, da Lei 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal, não vislumbro a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pondero que a quantidade de drogas apreendida foi pequena, não justificando a majoração da pena nesta fase.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes. Pondero que ainda que considerada sua confissão extrajudicial, esta não teria o condão de conduzir a pena aquém do mínimo legal, por força da Súmula n.º 231, do E. Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, da dosimetria, deve incidir a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4.º, da Lei 11.343/06. De acordo com entendimento amplamente majoritário do E. Supremo Tribunal Federal, "a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa" (HC n.º 124.107/SP, Primeira Turma, Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/11/14; HC n.º 122.626/SP, Primeira Turma, rel. Dias Toffoli, DJe de 17/11/14; RHC n.º 118.008/SP, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 19/11/13; HC n.º 108.388/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/4/13; Recurso Ordinário em HC n.º 116.049, rel. Dias Toffoli; HC n.º 111.309/DF, rel. Ministro Roberto Barroso).

No caso em tela, anoto que as circunstâncias não indicam que o acusado tenha envolvimento de forma reiterada ou profissional com a atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida. De fato, não há provas seguras de que o réu já praticava a traficância anteriormente, de modo que cabível a redução, no patamar de 2/3, levando-se em conta para a fixação deste patamar a quantidade de drogas apreendida.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do habeas corpus n.º 111.840-ES (Informativo STF n.º 507), ser inconstitucional a fixação obrigatória de regime

inicial fechado, consoante dispõe o § 1.º, art. 2.º, da Lei n.º 8.072/90, com as alterações decorrentes da Lei n.º 11.464/07. Assim, de acordo com referido precedente, compete ao juiz, analisadas as especificidades do caso concreto, fixar o regime inicial de cumprimento de acordo com as disposições do art. 33, do Código Penal.

Este mesmo entendimento deve ser aplicado no caso em tela, quer pela chamada "objetivação do controle difuso" (tese adotada e aplicada pelo E. Supremo Tribunal Federal), quer em sede de controle difuso de constitucionalidade por este Magistrado, declarando-se a inconstitucionalidade, incidenter tantum, do dispositivo legal em comento. De fato, a fixação a priori, pelo legislador, de um regime inicial de cumprimento, sem permitir que o Magistrado possa aferir, no caso concreto, qual o regime mais adequado para o sentenciado, com análise dos requisitos objetivos e subjetivos, fere o princípio implícito da proporcionalidade e o princípio da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5.º da CF/88). Partindo desta premissa, passo a fixar o regime inicial de cumprimento de pena. Considerando a quantidade de pena fixada (inferior a 04 anos), a primariedade do agente, bem como o tempo da prisão preventiva, fixo o regime inicial aberto, por entender, diante destas circunstâncias, ser este regime suficiente para fins de reprovação e prevenção da conduta a ele imputada.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de: (a) condenar LUCAS SILVA BEZERRA qualificado nos autos, à pena 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e ao pagamento de 166 dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal, por infração ao artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06.

(b) absolver ALEXSANDRA DA CONCEIÇÃO GUERREIRO, qualificada nos autos, em relação ao delito descrito na denúncia, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Fixo, desde logo, as seguintes condições para cumprimento da pena em regime aberto para LUCAS (art. 115, da Lei n.º 7.210/84):

- (a) permanecer em sua residência durante o repouso e nos dias de folga;
- (b) sair para apenas para tratamento médico, estudo ou trabalho, retornando ao término do expediente;
- (c) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia autorização judicial;
- (d) comparecimento periódico em Juízo (em prazo a ser fixado no Juízo da Execução Criminal), para informar e justificar as suas atividades.
- (e) Não frequentar determinados lugares, a saber: pontos de venda de drogas ("biqueiras"), locais e eventos em que sejam oferecidas ao público, de forma gratuita ou onerosa, bebidas alcoólicas para consumo imediato (bares, bailes, festas, "baladas" e congêneres).

Considerando os precedentes do E. Supremo Tribunal Federal em casos assemelhados, a Resolução n.º 05, do Senado Federal, bem como a presença das condições legais para tanto (art. 44, do Código Penal), substituo a pena privativa de liberdade de LUCAS por duas restritivas de direitos, uma na modalidade prestação de serviços à comunidade (art. 43, inciso IV, do CP), e outra na modalidade prestação pecuniária (art. 43, inciso I, do CP), eis que a pena aplicada é superior a 01 (um) ano, na forma do artigo 44, § 2.º, do Código Penal.

A prestação de serviços à comunidade deverá ser cumprida em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos ou outros, na forma do artigo 46 do Código Penal, devendo tal local ser indicado pelo Juízo da Execução na forma do artigo 149 da LEP. As tarefas deverão ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, até que venha a totalizar a pena imposta, na forma do artigo 46, § 3.º, do Código Penal.

Já a prestação pecuniária, que fixo no mínimo legal de 01 (um) salário mínimo, consiste no pagamento de dinheiro a entidade pública ou privada de destinação social, a ser identificada pelo Juízo das Execuções Criminais.

As penas de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, que substituem a pena privativa de liberdade, são aplicadas sem prejuízo da multa

cominada cumulativamente, eis que a substituição em questão somente alcança a reprimenda corporal e não a pena de multa. Em caso de reconversão a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime aberto, com as condições acima. Considerando a quantidade de pena aplicada e o regime inicial de seu cumprimento, bem como a ausência dos requisitos legais que autorizam a prisão preventiva de LUCAS, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade. Ressalto que, ainda que descumpridas as cautelares fixadas, é incompatível com o regime fixado a decretação da prisão preventiva, sendo cabível, se o caso, a fixação de novas cautelares. Em relação a Alexsandra, em razão de sua absolvição, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Condeno o acusado LUCAS ao pagamento das custas, na forma do artigo 4.º, § 9.º, da Lei 11.608/03, ressalvada a hipótese de ser beneficiário da Assistência Judiciária. Proceda-se à destruição das drogas, na forma do art. 72, da Lei n.º 11.343/2006. Decreto a perda dos valores apreendidos, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, na forma do artigo 63 e §§ da Lei 11.343/06, em favor do FUNAD/SENAD.

Transitada em julgado:

a) expeça-se certidão da sentença para fins de execução da pena de multa (artigos 479-A e 480, das NSCGJ), bem como guia de execução definitiva, e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime;

b) oficie-se ao IIRGD;

c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral;

Expeça-se o necessário.

Sentença publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

Diadema, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA